



**UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTU-
GUESA**

Arbitragem Voluntária Propriedade Intelectual

Notas sobre a arbitrabilidade da validade após a
transposição da Diretiva (UE) 2015/2436, que har-
moniza legislações dos Estados-Membros em ma-
téria de marcas

Trabalho I – Arbitragem Voluntária

Diogo Gaspar Sequeira – 340119055

Faculdade de Direito | Escola do Porto
Maio, 2026

“So far were the ancient Greeks affected
by the idea of arbitration that they assumed
its existence among the gods”

RALSTONE J. H., *International Arbitration from Athens to Locarno*,
Stanford University Press, California 1929, p. 153

Nota Prévia

No âmbito da avaliação contínua da Unidade Curricular de Arbitragem Voluntária, sob a docência do Prof. André Almeida Martins, foi-nos proposta a elaboração de um trabalho escrito, com a análise de uma questão relevante em face do conteúdo programático da disciplina. Na presente incursão, trataremos as especificidades da Arbitragem Voluntária enquanto meio de resolução de litígios em matéria de Propriedade Intelectual.

.

Índice

Nota Prévia	3
Lista de Siglas e Abreviaturas	5
Indicação geral sobre a forma de citar	7
1. Arbitragem, modalidades e comparação com os tribunais estaduais	8
1.1 Arbitragem: introdução	8
1.2 Particularidades do CPI vs. regime da LAV: contencioso das decisões administrativas do INPI	9
1.2.1 <i>Recorribilidade</i>	9
1.2.2 <i>Publicidade decisória</i>	10
2. Vantagens e limitações da AV na resolução de litígios relativos a DPI	11
2.1 Celeridade e especialização dos árbitros	11
2.2 Confidencialidade	12
3. Arbitrabilidade das diferentes categorias de DPI	14
3.1 Arbitrabilidade: visão geral, delimitação subjectiva e delimitação objectiva	14
3.2 Os DPI sujeitos a registo e os DPI não sujeitos a registo	15
3.2.1 <i>Os DPI não sujeitos a registo (o Direito de Autor)</i>	15
a) Direitos morais de autor	16
b) Direitos patrimoniais de autor	16
i) Arbitragem necessária para algumas categorias de litígios em matéria de direitos patrimoniais de autor	17
3.2.2 <i>Os DPI sujeitos a registo</i>	18
a) Quanto à validade	18
i) Sistema português desde 2003	18
ii) Transposição da DHM em 2019	18
iii) A apreciação da invalidade a título incidental: o primeiro grupo de DPI sujeitos a registo	19
iv) A apreciação da invalidade a título incidental: o segundo grupo de DPI sujeitos a registo	22
v) Notas de direito comparado	24
b) Quanto à titularidade	25
c) Obrigações contratuais (v.g., transmissão, licenciamento)	25
d) Obrigações extracontratuais (“infracção”)	25
4. Articulação do TA, INPI e ARBITRARE	26
4.1 O ARBITRARE: enquadramento institucional e evolução da arbitragem dos DPI sujeitos a registo em Portugal	26
4.2 Notas sobre a vinculação genérica do INPI à jurisdição do ARBITRARE	26
5. Conclusão	27
Lista de bibliografia consultada	29
Lista de jurisprudência e sentenças arbitrais	30

Lista de Siglas e Abreviaturas

Al(s). – Alínea(s)

ARBITRARE – ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações

Art(s). – Artigo(s)

AV – Arbitragem Voluntária

BPI – Boletim da Propriedade Industrial

CCiv – Código Civil (DL n.º 47344/66, 89.ª versão)

CDADC – Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (DL n.º 63/85)

CPC – Código de Processo Civil (Lei n.º 41/2013, 16.ª versão)

CPI 2003 – Código da Propriedade Industrial de 2003 (DL n.º 36/2003)

CPI 2018 – Código da Propriedade Industrial de 2018 (DL n.º 110/2018)

CRP – Constituição da República Portuguesa

DAC – Directiva 92/100/CEE, do Conselho, de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos ao direito de autor em matéria de propriedade intelectual

DED – Departamento de Extinção de Direitos (Unidade Orgânica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.)

DHM - Directiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

DMUD – Directiva Mercado Único Digital (Directiva (UE) 2019/790, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital)

DPI – Direito de Propriedade Intelectual (ou direitos de propriedade intelectual)

DTR – Directiva 93/83/CEE, do Conselho, de 27 de Setembro de 1993, relativa à coordenação de determinadas disposições em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radio-difusão por satélite e retransmissão por cabo

et. al. – *et alii*

EUA – Estados Unidos da América

i.e. – *id est*

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.

LAV – Lei da Arbitragem Voluntária (Lei n.º 63/2011)

LAV 86 – Arbitragem Voluntária (Lei n.º 31/86)

LOSJ – Lei da Organização do Sistema Judiciário (Lei n.º 62/2013)

n.º - número

p. – página

PA – Processo Arbitral

pp. – páginas

SA – Sentença Arbitral

segs. – seguintes

STJ – Supremo Tribunal de Justiça

TA – Tribunal Arbitral

TC – Tribunal Constitucional

TE – Tribunal Estadual

TPI – Tribunal da Propriedade Intelectual

UE – União Europeia

v.g. – *verbi gratia*

vol. - Volume

Indicação geral sobre a forma de citar

As obras, na sua primeira indicação, citam-se pelo Autor, título, título da publicação no caso dos artigos, obra no caso de obras colectivas, editora, local, data e página.

As obras são citadas pela data de edição ou, quando sejam reimpressões, pela data da reimpressão, consultadas.

As citações subsequentes são feitas de forma abreviada.

As decisões judiciais nacionais são citadas pelo Tribunal, data (dia-mês-ano) e número do processo respectivos.

A jurisprudência nacional que não tenha outra indicação foi consultada em www.dgsi.pt

As traduções serão, salvo diferente indicação, da responsabilidade do autor.

Foram tidos em conta elementos publicados até **8 de Maio de 2026**.

Salvo indicação em contrário, todos os links foram consultados pela última vez no dia **8 de Maio de 2026**.

1. Arbitragem, modalidades e comparação com os tribunais estaduais

1.1 Arbitragem: introdução

A arbitragem pode ser definida como um modo de resolução de litígios entre duas ou mais partes, efectuada por uma ou mais pessoas que detêm poderes para esse efeito reconhecidos por lei, mas atribuídos por convenção das partes¹.

Dentro do campo do direito arbitrável, é admissível às partes submeter à decisão a um ou a vários terceiros, independentes e imparciais², que decidem a causa que lhes é submetida, de forma vinculativa para as partes³.

Os tribunais arbitrais são constituídos por particulares, e como jurisdição privada⁴ que são, carecem de poder de autoridade (*imperium*), não dispõe de competência executiva para, autonomamente, efectivar as suas decisões⁵, entenda-se, impor, pela força, a sua decisão caso esta não seja voluntariamente cumprida pela parte, necessitando, nesse caso, a necessária colaboração dos tribunais estaduais. Não obstante, o árbitro é dotado de poder declarativo pleno, o árbitro não sofre, no que respeita ao poder declarativo, de qualquer *capitis diminutio* em relação ao juiz estadual⁶, faltando-lhe apenas o *imperium*.

Contudo, por se tratar de uma jurisdição privada, nem todos os litígios podem a ela ser submetidos, e é este o ponto sensível, ou seja, discernir quais as disputas que o Estado permite que possam ser julgadas por árbitros, fora dos seus órgãos de soberania⁷, especialmente neste domínio. Antes de avançarmos para as especificidades que a arbitragem voluntária coloca no domínio de litígios atinentes a direitos de propriedade intelectual, é fundamental que se distinga as duas principais modalidades de arbitragem⁸: (i) arbitragem voluntária; e (ii) arbitragem necessária.

A arbitragem voluntária é aquela que se funda na vontade das partes: as partes num litígio, mediante cláusula compromissória ou compromisso arbitral (consoante a convenção de arbitragem seja anterior ou posterior ao litígio, respectivamente), optam por atribuir a competência para julgar o seu litígio por um tribunal arbitral, excluindo assim a competência para apreciar a questão

¹ MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem, Almedina, Coimbra, 2010, p. 31, n.º à margem 1. Para o Autor, esta “definição de arbitragem assim feita salienta os quatro elementos essenciais do conceito: a sua *função jurisdicional* (resolução de litígios), a fonte de que resulta (convenção de arbitragem), os *titulares da função arbitral* (os árbitros) e o *reconhecimento legal*.” *cit.*, p. 32.

² Art. 9.º, n.º 3 LAV, com respaldo constitucional nos artigos 203.º e 20.º, n.º 4 da CRP.

³ Cfr. ELSA DIAS OLIVEIRA, Arbitragem Voluntária – Uma Introdução, Almedina, Coimbra, 2020, reimpressão, 2021, p. 11.

⁴ Reconhecida pela CRP, nos artigos 202.º e 209.º, n.º2.

⁵ Cfr. MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual ..., *op. cit.*, p. 283, n.º à margem 294.

⁶ Cfr. eloquentemente enuncia no seu guião de conferência, JOSÉ MIGUEL JÚDICE, “A constituição do tribunal arbitral: características, perfis e poderes dos árbitros” In 2.º Congresso de Arbitragem da ACL, 2008.

⁷ Ponto que abordaremos adiante, aquando da “arbitrabilidade”.

⁸ Denominada distinção tradicional, cfr. ELSA DIAS OLIVEIRA, Arbitragem ..., *op. cit.*, p. 24.

pelos tribunais estaduais⁹. Na arbitragem necessária, este acordo não existe, o que releva não é a vontade das partes, o recurso à via arbitral é imposto imperativamente por lei caso as partes pretendem solucionar o seu litígio¹⁰; ou seja, é a própria lei que, em vez de confiar a resolução de certos litígios aos tribunais estaduais, impõe que as partes recorram aos tribunais arbitrais¹¹.

1.2 Particularidades do CPI vs. regime da LAV: contencioso das decisões administrativas do INPI

Identificado o quadro geral da arbitragem voluntária, impõe-se agora analisar as especificidades que o CPI introduz face ao regime da LAV, designadamente no que respeita ao contencioso das decisões administrativas do INPI. Com efeito, ao consagrar no arts. 47.º e 48.º do CPI um regime especial de arbitragem para este domínio, o legislador optou por derrogar algumas das soluções gerais da lei arbitral comum.

1.2.1 Recorribilidade

O princípio da definitividade da sentença arbitral constitui, actualmente, a regra geral¹² em matéria de sindicância do mérito das decisões arbitrais¹³. Com efeito, o art. 39.º, n.º 4 da LAV é claro ao dispor que “*salvo as partes terem expressamente previsto tal possibilidade na convenção de arbitragem*” a sentença arbitral não é susceptível de recurso para o tribunal estadual. Quem voluntariamente submete o seu litígio à jurisdição arbitral aceita, salvo convenção expressa em contrário, a definitividade da decisão daí resultante, sendo o recurso para os tribunais estaduais a excepção e não a regra. O CPI, todavia, consagra uma solução distintiva e mais favorável ao

⁹ Assim, no que diz respeito à AV, a competência jurisdicional dos árbitros e a própria jurisdição do tribunal arbitral radicam na vontade expressa pela autonomia privada das partes, sendo este princípio a “trave-mestra” de todo o processo arbitral.

¹⁰ No mesmo sentido, ELSA DIAS OLIVEIRA, *Arbitragem...*, *op. cit.*, p. 24

¹¹ MANUEL PEREIRA BARROCAS pugna que apenas a arbitragem voluntária é verdadeira arbitragem, pois só esta assenta na vontade das partes de excluir a competência de apreciação do seu litígio aos tribunais estaduais e remetê-la aos tribunais arbitrais: “Ao contrário de outros autores, entendemos que a natureza jurídica da arbitragem necessária, isto é, imposta por lei como único meio contencioso susceptível de ser usado, não corresponde à que é própria de uma verdadeira arbitragem.” “A arbitragem, é, por sua natureza, convencional, isto é, baseia-se e tem o seu fundamento numa convenção de arbitragem”. “Ora, é neste substrato essencial que se baseia toda a razão de ser a função da arbitragem.”, *cit.*, MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual...*, *op. cit.*, pp. 89-90, n.ºs à margem 97 e 98.

¹² “O princípio da definitividade da sentença arbitral tem sido acolhido por um número crescente de países (...)”, MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual...*, *op. cit.*, *cit.*, p. 494, n.º à margem 521, mas nem sempre foi assim, como assinala o Autor. No contexto da LAV 86, o Autor refere que “a criação de uma cultura de arbitragem leva tempo, pois opera de modo difuso, mediante a influência de um clima de informação que esteja propício ao desenvolvimento de um certo cosmopolitismo jurídico. Enquanto esse ambiente favorável à adopção da arbitragem e à aceitação da sua autonomia plena relativamente aos tribunais não existir numa determinada comunidade, a arbitragem não atingiu ainda a sua maturidade (...) É o que ainda ocorre, presentemente, no texto da LAV [86]”, *op. cit.*, *cit.*, p. 497, n.º à margem 522.

¹³ MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual...*, *op. cit.*, “A adopção do princípio da definitividade da sentença arbitral é, assim, um tema de identidade e de cultura da arbitragem” “Introduzir a arbitragem nos tribunais judiciais e a revisão do mérito da causa por estes é negar ou fortemente limitar o interesse da sua existência. Por esta razão, a maior parte das cláusulas arbitrais que conhecemos já há muito que nelas se prevê a renúncia aos recursos” *cit.*, pp. 497-498, n.º à margem 522.

controlo judicial. Nos termos do art. 48.º, n.º 5 “*sempre que o INPI se encontre vinculado*” ao compromisso arbitral e a parte contrária aceite esse compromisso arbitral “*há possibilidade de recurso da decisão arbitral que vier a ser proferida para o tribunal da relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal da propriedade intelectual, nos termos da legislação processual civil*”¹⁴. Desta forma, o legislador subverteu a lógica subjacente ao regime-regra da LAV: neste contexto, a recorribilidade não é uma faculdade dependente da vontade das partes, mas sim uma faculdade que decorre de imposição legal, operativa sempre que o compromisso arbitral seja validamente celebrado.

1.2.2 Publicidade decisória

Na arbitragem voluntária, vigora o princípio da confidencialidade. O art. 30.º, n.º 5 da LAV impõe ao tribunal arbitral, aos árbitros, às partes e, se for o caso, as entidades que promovam, com carácter institucionalizado, o dever de sigilo “*sobre todas as informações que obtenham e documentos que tenham conhecimento através do processo arbitral*” – dever de confidencialidade esse que se estende à própria sentença arbitral, nos termos do n.º 6 do referido artigo – “*o disposto no número anterior não impede a publicação de sentenças e outras decisões do tribunal arbitral, expurgadas dos elementos de identificação das partes, salvo se qualquer destas a isso se opuser*”

Trata-se de um regime de confidencialidade tendencialmente amplo, coerente com a natureza privada da arbitragem e com as legítimas expectativas de quem a ela recorre.

O CPI, contudo, comporta uma solução diversa. Nos termos do art. 47.º, n.º 3 do CPI, “*o tribunal arbitral pode determinar a publicidade da decisão, nos termos do n.º 5 do artigo 34.º*”. Esta faculdade atribuída aos árbitros constitui uma derrogação do regime de confidencialidade que a LAV consagra como princípio geral: ao invés de depender de acordo das partes, a decisão sobre a divulgação pública da sentença fica aqui nas mãos do próprio tribunal. A este propósito, importa ainda atentar no disposto no art. 35.º, n.º 5 do CPI, que prevê, “*quando a decisão definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete a mesma para o INPI (...) para efeitos de publicação do respectivo texto e correspondente aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem como o seu respectivo averbamento*”¹⁵. Sobre o regime do CPI, desenvolveremos adiante.

¹⁴ Que será o Tribunal da Relação de Lisboa. O art. 111.º, n.º 1 al. e) da LOSJ atribui ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) competência para conhecer os recursos das decisões do INPI. O art. 83.º, n.º 3, da mesma lei, conjugado com o seu n.º 4 e o respectivo Anexo III, fixa a sede do TPI em Lisboa. Por seu turno, o art. 63.º, n.ºs 3 e 5 da LOSJ prevê a existência de uma secção especializada em matéria de propriedade intelectual no Tribunal da Relação de Lisboa. Finalmente, o art. 68.º, n.º 2, do CPC estabelece a regra geral da competência dos tribunais da Relação em matéria de recursos.

¹⁵ *Obiter dicta*, o art. 35.º, n.º 5 encerra uma manifesta imprecisão de redacção: o n.º 5 do art. 35.º remete para “os casos previstos no n.º 1” sendo que esses casos “*só podem resultar de decisão judicial*”. A norma deveria referir “os casos previstos no n.º 1 e n.º 2”, pois apenas as decisões do n.º 2 do artigo 34.º são susceptíveis de recurso arbitral... O n.º 1 tem por objecto as decisões proferidas por tribunais judiciais, pelo que nunca poderia ser essa a remissão legal

2. Vantagens e limitações da AV na resolução de litígios relativos a DPI

Como ponto de partida, cumpre assinalar que os litígios relativos a DPI cresceram significativamente em número e em valor nas últimas décadas, uma vez que o recurso aos TE para a sua resolução é frequentemente moroso e complexo, designadamente em casos transfronteiriços, o que tem favorecido um crescente recurso à arbitragem neste domínio¹⁶.

Com efeito, a arbitragem entre particulares, neste domínio, é encarada como uma via especialmente atractiva, pelas vantagens que apresenta em comparação com os tribunais estaduais, designadamente, a maior rapidez e “informalidade” na condução do processo, a especialização técnica dos árbitros, que por sua vez são escolhidos pelas partes, o carácter confidencial (no sentido de não ser um processo público), a produção de todos os meios de prova admitidos em direito¹⁷ e a sua melhor adequação para lidar com litígios de natureza internacional¹⁸.

Tais vantagens não estão, contudo, isentas de limitações, designadamente quando confrontadas com as especificidades do regime dos DPI – em particular, dos DPI sujeitos a registo. Importa, por isso, examiná-las com algum detalhe.

2.1 Celeridade e especialização dos árbitros

A morosidade dos tribunais estaduais constitui uma das principais razões que motivam o recurso à arbitragem. Mas, em bom rigor, resulta da própria natureza da arbitragem, quer pela disponibilidade dos árbitros, quer pelas próprias regras que regulam a arbitragem, que os interesses serão compostos com maior rapidez do que se fossem apreciados por um tribunal estadual, que terá de aplicar as regras processuais civis vigentes no seu ordenamento jurídico – ou seja, não é tanto a morosidade dos tribunais estaduais, mas sim a celeridade inerente ao processo arbitral. As regras que regulam o processo arbitral, com ressalva das “regras fundamentais”¹⁹ de garantia de um processo equitativo, estão na esfera da autonomia privada das partes²⁰, podendo prever prazos mais curtos para os actos processuais e regular a recorribilidade das decisões adoptadas, pelo que naturalmente serão proferidas decisões mais céleres²¹.

Em sentido próximo, releva a especialização dos árbitros: ao contrário do juiz estadual, os

de uma norma que regula os efeitos de uma decisão arbitral.

¹⁶ Como assinalado por DÁRIO MOURA VICENTE, “*Arbitrability of intellectual property disputes: a comparative survey*”, In *Arbitration International*, vol. 31, Oxford University Press, 2015, p.151

¹⁷ Cfr., nomeadamente, o art. 25.º do Regulamento de Arbitragem do ARBITRARE.

¹⁸ Entre outros, CÉSAR BESSA MONTEIRO “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, In *Jornal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, Anos XIII, n.º 4, Dezembro 1998, p. 12, ANTÓNIO CAMPINOS, LUÍS COUTO GONÇALVES, et al. (coordenadores), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2015, pp. 159-163 [ainda sob a vigência do CPI 2003] e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2025, pp. 654-655.

¹⁹ Art. 30.º, n.º 1 als. a), b) e c) LAV.

²⁰ Para o efeito, “autonomia processual das partes”.

²¹ No mesmo sentido, ELSA DIAS OLIVEIRA, *Arbitragem ...*, op. cit., p. 20.

árbitros são designados pelas partes; e as partes tendem a designar pessoas como árbitros em função das suas competências em determinadas áreas, permitindo assim que o litígio seja apreciado por pessoas com conhecimento aprofundado na matéria em apreço²². Em matéria de DPI, assume especial relevância esta vantagem apontada à arbitragem, uma vez que frequentemente os litígios nesta matéria cruzam conhecimentos jurídicos e conhecimentos técnicos (engenharia, química, biotecnologia, ciências da computação, etc.) o que permite aproximar a decisão da efectiva compreensão do *thema decidendum*.

2.2 Confidencialidade

A confidencialidade é, sem dúvida, uma característica atraente da arbitragem neste domínio, pois, através deste meio, preservam-se a imagem das partes, intimidades dos seus negócios, *know-how*/segredos de negócio, etc.²³, ponto que desenvolveremos adiante.

Em coerência com a sua natureza privada, a arbitragem voluntária é, por regra, uma jurisdição confidencial. Como já assinalado *supra*, o art. 30.º, n.º 5 da LAV, impõe um dever de sigilo aos árbitros, às partes e, sendo o caso disso, às entidades que, com carácter institucionalizado, promovam a arbitragem, dever esse que abrange todas as informações e documentos de que tenham conhecimento por via do processo arbitral.

Quanto à própria SA, o art. 30.º, n.º 6 da LAV permite a publicação das sentenças e demais decisões do tribunal arbitral, desde que “*expurgadas dos elementos de identificação das partes, salvo se qualquer destas a isso se opuser*”. Em abstracto, encontra-se assim assegurada uma confidencialidade tendencialmente absoluta, na medida em que a publicidade da decisão é, simultaneamente, condicionada e anonimizada (por ser “*expurgada*”).

A concretização do regime descrito na *praxis* demonstra, que esta confidencialidade tende a esbater-se quando estão em causa litígios envolvendo DPI sujeitos a registo – em especial, marcas e nomes de domínio. A razão é simples: sendo a SA publicada no *website* do ARBITRARE, ainda que expurgada “*dos elementos de identificação das partes*”, como a marca tem origem num acto público de concessão, com um número de registo associado, e o nome de domínio é meramente um endereço na Internet para aceder a um *website*²⁴, é trivialmente reconstruível quem são

²² No mesmo sentido, ELSA DIAS OLIVEIRA, Arbitragem ..., *op. cit.*, p. 20.

²³ “O processo arbitral é privado. O processo judicial cível é público. Aquele pode razoavelmente garantir a confidencialidade dos documentos que se utilizaram para prova dos factos. O processo civil não pode. A confidencialidade do processo arbitral é, pois, uma qualidade que pode favorecer as empresas que não desejam ver conhecidos do público e, sobretudo, da concorrência certos documentos” *cit.*, MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual..., *op. cit.*, p. 764, n.º à margem 820.

²⁴ “Os endereços do protocolo IP são constituídos por grupos de algarismos e letras sendo de difícil memorização. Como não seria prático para os utilizadores recorrerem a navegação directa por IP, desenvolveu-se também o sistema de nomes de domínio (DNS). Assim, em vez de escrever esse número, o utilizador escreve um endereço (v.g. www.nss.pt) e o sistema informático que sustenta os nomes de domínio fará a correspondência entre essa palavra e o

as partes²⁵, uma vez que do objecto da sentença decorrem elementos que permite identificar indirectamente as partes. Assim sendo, para as partes conseguirem obter um maior grau de confidencialidade, devem se opor, nos termos do referido artigo, à publicação, *a priori* permitida, da decisão pelo tribunal arbitral. Quando muito, a expurgação dos elementos identificadores das partes preserva a identidade do demandado²⁶.

A esta “erosão” da confidencialidade, acresce uma derrogação do princípio da confidencialidade, consagrada no art. 47.º, n.º3 do CPI, segundo o qual “*o tribunal arbitral pode determinar a publicidade da decisão nos termos do n.º5 do artigo 34.º*”. Trata-se de uma faculdade exercida pelo próprio TA – não dependente, portanto, do consentimento das partes, nos termos conjugados com o disposto no art. 34.º, n.º5 do CPI; nos termos desta última, transitada em julgado a decisão definitiva, a secretaria do tribunal remete ao INPI para efeitos de publicação do respectivo texto e correspondente aviso no BPI, bem como do respectivo averbamento.

Esta solução é coerente com a natureza dos DPI sujeitos a registo, precisamente porque produzem efeitos *erga omnes*, a publicidade do “desfecho” do litígio sobre a sua validade cumpre uma função informativa relevante para terceiros, justificando-se assim, em nome da segurança jurídica registal e do interesse público subjacente ao sistema. Implica, todavia, reconhecer que, neste domínio, o legislador optou por uma compressão do princípio geral da confidencialidade da arbitragem.

Em síntese, a confidencialidade da arbitragem em matéria de DPI sujeitos a registo é, em larga medida, uma confidencialidade *limitada*: subsistem ganhos relativos ao contencioso perante um TE, sobretudo quanto ao *iter* do processo arbitral (o art. 34.º, n.º5 do CPI apenas refere o “respectivo texto” da “decisão definitiva”, pelo que os articulados, a prova produzida, etc., não são publicados), mas dificilmente se impede a identificação das partes ou, em certos casos, da própria decisão.

respectivo endereço alfanumérico.” “Este endereço tem valor económico e transacionável, cabendo na noção jurídica de coisa (art. 204.º CC)” *cit.*, NUNO SOUSA E SILVA, Lições de Direito Digital, Almedina, Coimbra, 2026, p.168.

²⁵ Veja-se, p.ex., esta SA relativamente a nomes de domínio: ARBITRARE, Processo n.º 91/2025, “vinhosverdes.pt”; e esta SA relativamente a marcas: ARBITRARE, Processo n.º 17/2024 “registo da marca nacional n.º 707581 ‘SOLAR DOS PRESUNTOS’”

²⁶ Entenda-se, a parte não titular do DPI.

3. Arbitrabilidade das diferentes categorias de DPI

3.1 Arbitrabilidade: visão geral, delimitação subjectiva e delimitação objectiva

Antes de qualquer litígio poder ser apreciado num TA é necessário saber se, em primeiro lugar, este é susceptível de ser submetido ou não à “decisão de árbitros”²⁷; ou seja, é necessário saber se tal litígio é ou não arbitrável²⁸, para determinar se este pode ser validamente resolvido pelo recurso à arbitragem. Este requisito prévio da arbitragem tem duas vertentes, conhecidas geralmente por: (i) arbitrabilidade subjectiva e (ii) arbitrabilidade objectiva²⁹.

A primeira prende-se com a capacidades das partes para celebrar uma convenção de arbitragem (a submissão de um litígio a arbitragem depende da capacidade das partes³⁰).

A questão coloca-se com maior pertinência relativamente à susceptibilidade de o Estado, *lato sensu*, poder ser parte no processo arbitral, o que a nossa LAV responde de forma afirmativa³¹.

A segunda tem que ver com o tipo de litígios arbitráveis em função da natureza do objecto da questão controvertida. O critério adoptado pela LAV 86 era o da disponibilidade do direito³², critério esse que era de difícil concretização, precisamente por não ser muito claro³³. Para o efeito, a actual LAV resolve este problema, ao prever como critérios gerais da arbitrabilidade³⁴: o litígio terá de respeitar a interesses de natureza patrimonial *ex vi* art. 1.º, n.º 1 LAV (critério da patrimonialidade) ou, mesmo que não envolvam estes interesses, as partes terão de poder celebrar transacção sobre o direito controvertido *ex vi* art. 1.º, n.º 2 LAV (critério da transigibilidade). Realçamos, não obstante, que encontramos subsídios do critério da disponibilidade do direito como critério de arbitrabilidade na actual LAV, por remissão do instituto da transacção, uma vez que o art. 1.º, n.º 2 LAV estabelece que “é também válida a convenção de arbitragem relativa a litígios que não envolvam interesses de natureza patrimonial desde que as partes possam celebrar transacção sobre o direito controvertido”, o que naturalmente remete para o art. 289.º do CPC, que, por sua vez, indica que não é permitida a transacção relativamente a direitos indisponíveis³⁵.

²⁷ Art. 1.º, n.º 1 LAV, *in fine*.

²⁸ “A arbitrabilidade constitui matéria de maior importância no estudo da arbitragem. Pode existir convenção de arbitragem e cumpridos todos os requisitos de validade, mas se o litígio não for arbitrável não é possível resolvê-lo pelo recurso à arbitragem” *cit.*, MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual... *op. cit.*, p. 215, n.º à margem 242.

²⁹ MANUEL PEREIRA BARROCAS, *op. cit.*, pp. 99-105.

³⁰ Mais desenvolvidamente, MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual... *op. cit.*, pp. 219-220, n.º à margem 244.

³¹ Art. 1.º, n.º 5 LAV, “(...) na medida em que para tanto estejam autorizados por lei ou se tais convenções tiverem por objecto litígios de direito privado”

³² Art. 1.º, n.º 1 LAV 86.

³³ *Vide*, MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual... *op. cit.*, pp. 216-217, onde realçamos “A nova lei de arbitragem portuguesa que se deseja deverá, obviamente, tomar posição sobre uma melhor caracterização da arbitrabilidade do que faz a LAV [86]”, *cit.*, p. 217.

³⁴ ELSA DIAS OLIVEIRA, Arbitragem..., *op. cit.*, p. 36.

³⁵ Nos termos do art. 1249.º CCiv.

3.2 Os DPI sujeitos a registo e os DPI não sujeitos a registo

Para fazer um levantamento global dos diferentes modelos adoptados pelos diversos ordenamentos jurídicos relativamente à arbitrabilidade objectiva dos litígios envolvendo DPI, DÁRIO MOURA VICENTE distingue entre: DPI sujeitos a registo (v.g., patentes e marcas) e DPI não sujeitos a registo³⁶, cujo paradigma é o *copyright*³⁷, *summa divisio* que utilizaremos também para melhor expor as particularidades que cada categoria de DPI coloca relativamente à arbitrabilidade.

Adiantamos, desde já, que a questão mais controversa neste quesito reside na arbitrabilidade dos litígios sobre a *validade* desses direitos^{38,39}.

Importa, ainda que apenas para efeitos da presente exposição como instrumento de trabalho, distinguir as diferentes categorias de questões⁴⁰ cuja (in)arbitrabilidade pode estar em causa. São elas:

- a) a **validade** dos DPI;
- b) a **titularidade** dos DPI;
- c) as **obrigações contratuais** (v.g., transmissão, licenciamento) cujo objecto seja um DPI;
- d) as **obrigações extracontratuais** resultantes da “infracção”⁴¹ dos DPI.

3.2.1 Os DPI não sujeitos a registo (o Direito de Autor)

Os DPI não sujeitos a registo, cujo paradigma é o direito de autor, que nasce automaticamente com a criação⁴² da obra⁴³, independentemente de qualquer formalidade, tem um carácter dual: *i.e.*, desdobra-se em duas ordens (*ex vi* art. 9.º, n.º 1 CDADC), direitos pessoais (ou morais) e

³⁶ “To answer this question, we shall distinguish two basic types of IP rights: those that ordinarily require registration and those that do not.”, *cit.*, DÁRIO MOURA VICENTE, “Arbitrability...” *op. cit.*, p. 152.

³⁷ Art. 12.º CDADC.

³⁸ Questão que não é desprovida de interesse prático, uma vez que o art. 46.º, n.º 3, al. b), i) permite a anulação da sentença arbitral se “o objecto do litígio não [for] susceptível de ser decidido por arbitragem”, excepção essa que é também de conhecimento oficioso mediante um pedido de anulação.

³⁹ “Embora nada impeça a submissão a arbitragem voluntária (nos termos gerais) de outros litígios relativos a DPI, importa – pela sua especial relevância e expressão prática – fazer uma referência mais desenvolvida ao regime do recurso arbitral previsto no CPI e à arbitragem relativa a patentes de medicamentos de referência, instituída pela Lei 62/2011, de 12 de Dezembro”, *cit.*, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, *op. cit.*, p. 654.

⁴⁰ A mesma distinção e categorização das questões é feita por DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, p. 471.

⁴¹ Por “infracção” entenda-se todos os litígios referentes às obrigações extracontratuais (v.g., indemnização, restituição do enriquecimento sem causa) emergentes da violação de direitos de propriedade intelectual – não sendo relevante, para efeitos da presente incursão, se as partes tinham, ou não, um vínculo jurídico prévio.

⁴² “Definimos criação como o acto de exteriorização formal de uma obra intelectual”, *cit.*, ALBERTO SÁ E MELLO, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, 6.º edição, Almedina, Coimbra, 2025, p. 76.

⁴³ “É, pois, certo que a constituição da situação jurídica do direito de autor pela exteriorização da obra não depende da vontade do seu autor-criador, pelo que o efeito jurídico desta acção é independente da vontade do sujeito; e, neste sentido, é mero facto jurídico.”, *cit.*, ALBERTO SÁ E MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, 6.º edição, Almedina, 2025, p. 77.

direitos patrimoniais. Neste dualismo reflecte-se o facto de a obra ser simultaneamente um bem susceptível de constituir objecto de transacções económicas e a expressão da personalidade do autor, tributário do sistema personalista do Direito de Autor, cuja nossa tradição jurídica herdou das leis francesas do final do séc. XVIII redigidas por LE CHAPELIER⁴⁴ (*droit d'auteur*).

a) Direitos morais de autor

Feita esta distinção, os direitos morais de autor (v.g., direito à paternidade⁴⁵, à integridade⁴⁶, o direito à menção do nome na obra⁴⁷, etc.) são, nos sistemas do tipo continental, direitos de personalidade, inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis (art. 56.º, n.º 2 CDADC) e independentes dos direitos patrimoniais. Consequentemente, seguindo o critério adoptado pelo legislador português no art. 1.º, n.º 1 e n.º 2 da LAV, litígios que tenham por objecto estes direitos (ou o carácter moral destes direitos) não são arbitráveis, por não serem litígios de natureza patrimonial⁴⁸.

Há, no entanto, uma nuance no que toca aos direitos morais de autor: o autor pode consentir na modificação da sua obra por terceiros⁴⁹ ou à sua publicação sem indicação de autoria⁵⁰; tais negócios jurídicos respeitam ao *exercício* dos direitos morais e não à sua *disposição*⁵¹, pelo que os litígios deles emergentes são arbitráveis⁵².

b) Direitos patrimoniais de autor

Quanto aos direitos patrimoniais de autor – que, segundo o art. 9.º, n.º 2 do CDADC, no exercício dos direitos de carácter patrimonial, “(...) o autor tem o direito exclusivo de dispor da sua obra e de fruí-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou

⁴⁴ LE CHAPELIER, relator da *Loi du 13 janvier 1791 Relative aux Spectacles*, declarou perante *L'Assemblée Nationale* que “*La plus sacrée, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain*”. É uma forma totalmente diferente de pensar o direito de autor vs a concepção do *copyright* uma vez que tem como postulado que o direito de autor é um *direito de propriedade* com *carácter sacramental*, ao contrário da visão anglo-saxónica que é muito mais “*society-focused*” entendendo este como um “mero” monopólio legal, um exclusivo atribuído por lei, cuja finalidade é a promoção da criação literária, artística e científica. Consequentemente, o *droit d'auteur* nasce com a criação da obra – não através da lei (como na *common law*); no sistema continental o Direito limita-se a *reconhecer* a obra.

⁴⁵ Art. 27.º CDADC

⁴⁶ Art. 56.º, n.º 1 CDADC

⁴⁷ Art. 76.º, n.º 1, al. a) CDADC

⁴⁸ No mesmo sentido, DÁRIO MOURA VICENTE, *op. cit.*, p. 159

⁴⁹ Cfr. os arts. 15.º, n.º 2, 45.º, n.º 2, 59.º, n.º 1, e 115.º, n.º 3 do CDADC.

⁵⁰ Art. 30.º CDADC.

⁵¹ Mais desenvolvidamente, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos conexos: Direito Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 1992, reimpressão, 2008 *cit.*, p. 193., sujeita estes negócios jurídicos ao regime das faculdades patrimoniais, e não dos direitos morais de autor. No mesmo sentido, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...*, *op. cit.*, p. 477.

⁵² “Tais negócios, na medida em que correspondam a atos de *exercício* e não de *disposição* dos direitos morais de autor, são compatíveis com a proibição legal de cessão ou renúncia a estes. Os litígios resultantes desses negócios são, assim, arbitráveis nos mesmos termos em que o são os litígios emergentes do exercício de direitos patrimoniais” *cit.*, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...*, *op. cit.*, p. 477.

parcialmente”⁵³ – a sua arbitrabilidade é consensual, “nenhuma razão de interesse público”⁵⁴ obsta à composição de interesses que os tenham por objecto. Este entendimento é confirmado pelo art. 1.º, n.º 1 da LAV, que admite que “qualquer litígio respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes (...) à decisão de árbitros”

Uma excepção relevante nos direitos patrimoniais de autor é o *droit de suite* (direito de sequência), consagrado no art. 54, n.º 1 do CDADC, que atribui ao autor de obra de arte original um direito inalienável de participação nas vendas sucessivas da mesma. Sendo um direito indisponível, os litígios que o tenham por objecto não são, em princípio, submetíveis a arbitragem⁵⁵.

i) Arbitragem necessária para algumas categorias de litígios em matéria de direitos patrimoniais de autor

Na sequência da transposição da DMUD, o DL n.º 47/2023 introduziu no ordenamento jurídico português a previsão que “a resolução de litígios em matéria de direito de autor e direitos conexos” fica a cargo de “centro de mediação e arbitragem institucionalizada especializado na matéria”⁵⁶. Das decisões dos centros de mediação e arbitragem cabe recurso para o Tribunal da Relação, cfr. art. 8.º, n.º 5 do referido diploma. Em princípio, o recurso ao tal centro é facultativo, salvo previsão legal (art. 8.º, n.º 4 do referido diploma), pelo que *prima facie* a modalidade da arbitragem de litígios em matéria de direito de autor e direitos conexos é voluntária e não institucionalizada. Todavia, o legislador português foi mais longe, já aquando da transposição de Diretivas anteriores (a DAC e a DTR), ao prever mecanismos de arbitragem *necessária* para algumas categorias de litígios em matéria de direitos patrimoniais de autor, tais como: o art. 6.º, n.º 2 do DL n.º 332/97 (comodato público), o art. 7.º, n.º 3 do DL n.º 333/97 (transmissão por cabo), o art. 5, n.º 4 da Lei n.º 62/98 (compensação equitativa pela reprodução privada) e o art. 221.º, n.º 4 do CDADC (medidas tecnológicas de proteção e reprodução para uso privado)⁵⁷.

⁵³ No mesmo sentido, o art. 67.º do CDADC esclarece que “o autor tem o direito de fruir e utilizar a obra, no todo ou em parte (...)”. Assim sendo, o autor pode dispor da sua obra através dos mais variados meios de exploração como, por exemplo, a divulgação, a publicação e a distribuição, não sendo de qualquer modo taxativo quanto aos mesmos, nos termos do n.º 1 do art. 68.º do CDADC pois permite-a (“[...] por qualquer dos modos actualmente conhecidos ou que de futuro o venham a ser.”)

⁵⁴ “No reason of public interest, in fact, prevents arbitration in their respect” cit., DÁRIO MOURA VICENTE, “Arbitrability...”, *op. cit.*, p. 160.

⁵⁵ Tal como refere DÁRIO MOURA VICENTE, A Tutela..., *op. cit.*, p. 478 e, do mesmo Autor, *In Lei da Arbitragem Voluntária* Anotada, ARMINDO RIBEIRO MENDES... [et al.], Almedina, Coimbra, 2012, p. 16, em anotação ao artigo 1.º da LAV.

⁵⁶ Art. 8.º, n.º 1 do DL n.º 47/2023.

⁵⁷ Muito mais desenvolvidamente, vide VÍTOR PALMELA FIDALGO, “Proposta para a implementação de legislação sobre resolução alternativa de litígios em matéria de direito de autor e direitos conexos (Parecer)” *In* Propriedades Intelectuais, jun/nov 2023, n.ºs 19 e 20.

3.2.2 Os DPI sujeitos a registo

a) Quanto à validade

i) Sistema português desde 2003

No CPI 2003⁵⁸, no seu art. 35.º, n.º 1, lia-se que “a *declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial*”. Ou seja, até à revisão do CPI com a transposição da DHM⁵⁹, vigorava no ordenamento jurídico português um regime de inarbitrabilidade, a título de acção principal, da validade de todos os títulos de propriedade industrial⁶⁰, uma vez que estes se encontravam por lei especial submetidos exclusivamente aos tribunais do Estado (cfr. art. 1.º, n.º 1 LAV⁶¹). Apesar de ser líquida a questão da inarbitrabilidade dos litígios, entre particulares, relativos à validade dos títulos de propriedade industrial a título de acção principal, já nesta altura se discutia se a alegada invalidade de um título de propriedade industrial poderia ser conhecida a título incidental como excepção por um tribunal arbitral, questão essa que abordaremos adiante.

ii) Transposição da DHM em 2019

A DHM foi transposta e implementada no ordenamento jurídico português através do DL n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, que reformulou o até então vigente CPI 2003, passando a vigorar o CPI 2018. O artigo 2.º da Portaria n.º 326/2019, de 23 de Setembro, alterou os Estatutos do INPI⁶², aditando o artigo 7.º, onde se criou uma unidade orgânica – a Direção de Extinção de Direitos (DED) – que permitiu acomodar a nova competência resultante da transposição da DHM, implementada no CPI 2018, que impunha aos Estados-Membros a instituição de um “*procedimento administrativo eficiente e expedito de extinção ou declaração de nulidade de uma marca junto dos respectivos institutos*”⁶³.

Indo para além do conteúdo de transposição obrigatória da DHM, o legislador português adoptou esta solução (administrativa) para todos os demais sinais distintivos, até mesmo para os DPI relacionados com a tutela da inovação estética como os desenhos ou modelos. Na Portaria referida *supra*, lê-se que “*aproveitou-se igualmente a transposição deste diploma comunitário para alargar esta competência a outros registos.*” Pertinentemente, PEDRO SOUSA E SILVA dá nota que o legislador português optou por esta solução “sem enunciar minimamente as razões.”⁶⁴

Não obstante, desde a transposição da DHM, vigora no ordenamento jurídico português um

⁵⁸ DL n.º 36/2003, de 5 de Março.

⁵⁹ Sobre o interregno entre 2003 e 2019, voltaremos adiante.

⁶⁰ Todos os “DPI sujeitos a registo”.

⁶¹ A LAV 86, vigente até Janeiro de 2012, incluía igual restrição.

⁶² Portaria n.º 386/2012.

⁶³ Art. 45.º DHM.

⁶⁴ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, *op. cit.*, pág. 42.

“regime dual”⁶⁵ quanto à arbitrabilidade da validade dos DPI sujeitos a registo, consoante estejamos perante:

- i. DPI relacionados com a tutela da inovação técnica (patentes, certificados complementares de protecção, modelos de utilidade e topografias de produtos semicondutores⁶⁶), cfr. art. 34.º, n.º 1 CPI; ou
- ii. Outros direitos exclusivos (desenhos ou modelos, marcas, logótipos, denominações de origem, indicações geográficas e recompensas⁶⁷), cfr. art. 34.º, n.º 2 CPI.

Os litígios relativos à validade dos primeiros são inarbitráveis, uma vez que as respectivas declarações de nulidade ou anulações “*só podem resultar de decisão judicial*” (art. 34.º, n.º 1 CPI *in fine*), sendo este preceito uma “*lei especial*” que submete exclusivamente “*aos tribunais do Estado*” a apreciação desta matéria, nos termos do art. 1.º, n.º 1, 1.º parte, da LAV, *a contrario*.

Quanto ao segundo grupo, a validade é arbitrável *institucionalmente* – mais concretamente, é arbitrável o contencioso relativo às decisões do INPI sobre a nulidade ou anulação destes registos, uma vez que: (i) as declarações de nulidade ou anulação resultam de decisão do INPI, cfr. art. 34.º, n.º 2 do CPI; (ii) por resultarem de decisão do INPI relativa a “*declarações de nulidade ou anulações ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial*”, são susceptíveis de recurso judicial *ex vi* art. 38.º, al. b) do CPI; consequentemente, (iii) por se tratar de uma questão susceptível de recurso judicial, o art. 47.º, n.º 1 do CPI permite que seja constituído tribunal arbitral (através de requerimento por parte do interessado, de celebração de compromisso arbitral) nos termos do 48.º do CPI e, havendo contrainteressados (por exemplo, reclamantes), é também necessário que estes aceitem o compromisso arbitral (art. 47.º, n.º 2 do CPI)

Em suma, é permitida a sujeição a árbitros do contencioso relativo às decisões do INPI que, no exercício das competências da DED, anulem ou declarem nulos os registos do segundo grupo de DPI, sendo vedada a arbitrabilidade da validade dos DPI do primeiro grupo.

iii) A apreciação da invalidade a título incidental: o primeiro grupo de DPI sujeitos a registo

Como vimos, não se levantam grandes dúvidas relativamente à exclusão de arbitrabilidade do primeiro grupo de DPI sujeitos a registo, à luz da lei portuguesa, no que toca à sua apreciação a título principal e com efeitos *erga omnes*. Continua a ser discutido na doutrina e na jurisprudência se essa validade pode ser conhecida a título incidental, isto é, no contexto de litígios sobre

⁶⁵ PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial..., *op.cit.*, pág. 41.

⁶⁶ Doravante, “primeiro grupo de DPI sujeitos a registo”.

⁶⁷ Doravante, “segundo grupo de DPI sujeitos a registo”.

obrigações contratuais ou extracontratuais (chamemos-lhes litígios sobre “infracções”) em que, por exemplo, o réu se defende sustentando a invalidade do direito que contra si está a ser invocado.

A **posição favorável** é sustentada por DÁRIO MOURA VICENTE, que defende que a invalidade do primeiro grupo de DPI pode ser conhecida a título incidental por um tribunal arbitral, com meros efeitos *inter partes*, uma vez que, caso a mesma seja tida como demonstrada, o tribunal arbitral apenas a irá julgar *inoponível* entre as partes no processo que lhe compete julgar, não colidindo com a exclusão de arbitrabilidade da declaração de nulidade e da anulação decorrente do art. 34.º do CPI, valendo apenas, deste modo, para “a sua apreciação a título principal e com efeitos *erga omnes*; não para uma pronúncia *incidenter tantum*”⁶⁸. Na mesma linha, situam-se ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA^{69,70} – e no contexto específico do regime especial de arbitragem (outrora necessária) em matéria de medicamentos de referência e medicamentos genéricos (Lei n.º 62/2011), REMÉDIO MARQUES^{71,72,73}, ALEXANDRE SOVERAL MARTINS⁷⁴ e JOSÉ ALBERTO

⁶⁸ DÁRIO MOURA VICENTE, A Tutela..., *op. cit.*, p. 474.

⁶⁹ “Diferentemente, se o litígio tiver origem num contrato relativo a DPI (v.g., contratos de licença) – respeitando, por exemplo, à respectiva interpretação, validade ou extinção – bem como se estiver em causa a efectivação da responsabilidade contratual pela sua violação, nada permite fundar a inarbitrabilidade da controvérsia”, *cit.*, ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem de Litígios com Entes Públicos, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2015, pp. 46-47.

⁷⁰ “Se, por outro lado, no âmbito de uma arbitragem relativo a um litígio de cariz contratual, se colocar, em termos prévios ou incidentais, um problema da validade do título, admite-se que os árbitros conheçam da questão, embora com mera eficácia *inter partes*.”, *cit.*, ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem..., *op. cit.*, p. 47.

⁷¹ JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “A arbitrabilidade dos litígios e a dedução de providências cautelares por empresas de medicamentos de referência, na sequência da aprovação de medicamentos genéricos”, In Revista de Direito Intelectual, n.º 01-2014, Almedina, Coimbra, 2014, pp. 33 e segs. Em especial, o ponto 2.4, *cit.*, “A competência exclusiva dos tribunais estaduais para certas questões em matéria de propriedade industrial”, pp.48-65; e o ponto 2.5, *cit.*, “matérias excluídas da competência dos tribunais arbitrais necessários; em particular, o conhecimento da questão da invalidade da patente pelo tribunal arbitral necessário em matéria de defesa”, pp. 66-67

⁷² JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “A arbitrabilidade da exceção de invalidade de patente no quadro da Lei n.º 62/2011. Anotação ao Acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de fevereiro de 2014 (proc. n.º 1053/13.7YRLSB-2)” In Revista de Direito Intelectual, n.º 02-2014, Almedina, Coimbra, 2014, pp. 211 e segs. Destacamos, “Vistas as coisas a *jusante* (após ter transitado em julgado o acto administrativo de concessão do direito de patente), a *invocação e a declaração de nulidade somente pode ser efectuada nos tribunais judiciais*, pois neles está garantida a intervenção (principal ou espontânea) de todos os ‘contra-interessados’ (...)” “Já o conhecimento da falta de novidade ou actividade inventiva *por via de excepção deduzida* pelo réu (enquanto matéria de defesa), em acção de infracção da patente, não exige nem intervenção de contra-interessado, nem do Ministério Público. Motivo por que sempre foi admitido este meio de defesa (e não de contra-ataque) em acções de infracção nos tribunais judiciais.” “Ora, se a *montante* do nascimento do direito industrial, um tribunal arbitral pode destruir o acto administrativo que estatuiu autoritariamente sobre um pedido de protecção, a *jusante* do seu nascimento não repugna admitir que um tribunal arbitral possa conhecer a questão da falta de novidade ou de actividade inventiva, agora sob a veste de excepção peremptória da nulidade do direito já constituído, com meros efeitos *inter partes*” *cit.*, pp. 235-236.

⁷³ JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “*Bis in idem: em torno da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a questão da invalidade da patente com efeitos inter partes - anotação ao acórdão do STJ de 14 de Dezembro de 2016 (proc. n.º 1248/14.6YRLSB.S1)*”, In Revista de Direito Intelectual, n.º 01-2017, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 305 e segs. sublinhando que “o argumento que fortemente depõe a favor da tese veiculada neste acórdão do STJ é o suscitado por OEHEN MENDES”, preocupando-se em expor detalhadamente um conjunto de ideias que levam, no entender do Autor, a uma decisão diversa da que foi emitida pelo STJ.

⁷⁴ ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, “Arbitragem e propriedade industrial: medicamentos de referência e medicamentos genéricos”, In Revista de Legislação e Jurisprudência, 144.º ano, Julho-Agosto de 2015, n.º 3993, pp. 418 e segs. Destacamos, “O tribunal arbitral, uma vez constituído, deve notificar o demandado para que este apresente a

VIEIRA⁷⁵. O Tribunal Constitucional sufragou esta posição, ainda que apenas relativamente aos DPI cuja arbitragem era *necessária*, ao abrigo referida lei, no Acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017. O DL n.º 110/2018 que aprovou o CPI 2018 alterou também o regime da arbitragem *necessária* em matéria de medicamentos genéricos, passando esta a ser *voluntária*: o actual artigo 3.º, n.º 1 da Lei n.º 62/2011 determina que o titular da patente do medicamento de referência que queira invocar o seu direito deve fazê-lo junto do TPI ou, “*em caso de acordo entre as partes junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efectuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada*”. Com esta alteração, o legislador acolheu o entendimento do Tribunal Constitucional no acórdão referido *supra* que havia julgado inconstitucional o regime decorrente dos arts. 2.º da Lei n.º 62/2011 e dos arts. 35.º, n.º 1 e 101.º, n.º 2 do CPI 2003, na medida em que esse regime impedia que, no âmbito de arbitragem *necessária* instaurada ao abrigo daquela lei, o demandado se pudesse defender por via de excepção, invocando a invalidade da patente, com eficácia meramente *inter partes*⁷⁶.

Em sentido contrário, MANUEL OEHEN MENDES defende que a incompetência dos tribunais arbitrais em matéria de validade tem “natureza substantiva”^{77,78} e não meramente processual, sendo o art. 34.º, n.º 1 do CPI uma “norma de ordem pública”⁷⁹.

Para este Autor, aceitar a invalidade a título incidental com eficácia *inter partes* implicaria, no limite, que o direito absoluto registado seria inoponível ao infractor perante o tribunal arbitral, mas permaneceria oponível a todos os demais, o que criaria uma situação paradoxal de “nulidade

sua contestação (...) Nessa contestação pode, designadamente, ser alegada a *título de excepção a invalidade das patentes* (...)” “A título de excepção, dizemos, porque as acções de nulidade e de anulação previstas no CPI devem ser apreciadas nos termos do art 111.º, 1 da LOSJ (cfr. tb. o art. 35.º CPI [2003]) *cit.*, p. 427.

⁷⁵ JOSÉ ALBERTO VIEIRA, “*A competência de tribunal arbitral necessário para apreciar a excepção de invalidade de patente registada. Anotação ao Acórdão da Relação de Lisboa de 13 de Janeiro de 2015*” In Revista de Direito Intelectual, n.º 02-2015, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 195 e segs.

⁷⁶ No mesmo sentido, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial..., *op. cit.*, p. 656. Os argumentos a favor desta posição são invariavelmente condicionados pela *modalidade* da arbitragem em causa.

⁷⁷ “Se, por imperativo legal (art. 35.º, 1, do CPI) [atual 34.º, n.º 1 do CPI] os tribunais arbitrais não tiverem competência para tal, *ratione materiae*, seguramente que não poderão conhecer da invalidade das patentes, quer em via de acção, quer em via de excepção (...)” “A excepção dilatória da incompetência em razão da matéria tem natureza substantiva e não pode ser contornada através de um expediente processual: não seria aceitável que o tema da invalidade pudesse ser apreciado por um tribunal se fosse introduzido nos autos como uma excepção deduzida no âmbito da contestação, mas já não pudesse ser considerado e decidido pelo mesmo tribunal se lhe fosse apresentado em via de acção ou de reconvenção”, *cit.*, MANUEL OEHEN MENDES “*Breves considerações sobre a incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciar a questão da invalidade das patentes e dos Certificados Complementares de Protecção para Medicamentos*”, In DÁRIO MOURA VICENTE et al. (coordenadores), *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, 2015, p. 936

⁷⁸ “Se assim fosse, a incompetência dos tribunais arbitrais não seria uma incompetência *substantiva*, em razão da matéria, mas sim uma incompetência “adjetiva”, a decidir em função da *forma* ou do *meio* como a objecção fosse introduzida no processo” *cit.*, MANUEL OEHEN MENDES “*Breves considerações...*”, *op. cit.*, p. 936

⁷⁹ “Nos países em que a lei impede aos tribunais arbitrais o conhecimento da invalidade das patentes, como é o caso do nosso, a norma é geralmente considerada como uma norma de *ordem pública*, o que é facilmente compreensível, dada a natureza destes direitos e as garantias que eles pretendem atribuir aos seus titulares” *cit.*, MANUEL OEHEN MENDES “*Breves considerações...*”, *op. cit.*, p. 940

relativa” que atenta contra a natureza *erga omnes* dos títulos privativos industriais e, até mesmo, a própria finalidade do sistema de patentes⁸⁰. Neste sentido, pronunciam-se ainda EVARISTO MENDES⁸¹, MARGARIDA SAMEIRO⁸² e LUÍS COUTO GONÇALVES⁸³. O Supremo Tribunal de Justiça acolheu esta posição no Acórdão de 14 de Dezembro de 2016, proc. n.º 1248/14.6YRLSB.S1.

Entendemos que a posição mais adequada, ainda que *iure condendo* face à letra da lei, é a que admite o conhecimento incidental da invalidade com eficácia *inter partes*.⁸⁴ O art. 34.º, n.º1 do CPI não permite que a apreciação da validade com efeitos *erga omnes* seja subtraída à competência exclusiva dos tribunais estaduais: entendemos que uma pronúncia arbitral que se limite a declarar a *inoponibilidade* (por invalidade) do direito entre as partes concretas do litígio não colide com este imperativo. Entendemos que negar ao tribunal arbitral esta possibilidade obrigaria à suspensão da instância arbitral, enquanto se aguarda pronúncia judicial sobre a (in)validade do DPI, atenta a prejudicialidade desta questão face à principal⁸⁵, esvaziando em larga medida as vantagens da celeridade e confidencialidade que motivam o recurso à arbitragem, constituindo também um mecanismo “fácil” de “bloquear” a instância arbitral ao dispor do demandado que actue de má-fé.

iv) A apreciação da invalidade a título incidental: o segundo grupo de DPI sujeitos a registo

Mais espinhosa é a discussão quanto ao segundo grupo de DPI, tendo em conta a actual redacção resultante da transposição da DHM. A particularidade deste grupo reside em que a competência primária para declarar a nulidade ou anulação dos respectivos registos passou a caber ao INPI – mais concretamente, à DED – e não aos tribunais estaduais (art. 34.º, n.º 2 CPI 2018).

⁸⁰ “Introduzir no sistema de patentes a possibilidade de «determinação múltipla» da invalidade deste direito privativo, em termos que não permitam ultrapassar a relação entre as partes envolvidas num determinado litígio, poderia conduzir-nos a uma séria distorção da concorrência. Na medida em que, em resultado desse regime, uns ficariam livres de usar o invento patenteado, enquanto outros continuariam obrigados a não o fazer.” *cit.*, MANUEL OEHEN MENDES “Breves considerações...”, *op. cit.*, p. 937

⁸¹ EVARISTO MENDES, “Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efetiva e Questões Conexas”, In *Propriedades Intelectuais*, 2015, n.º 3, pp. 103 e segs.

⁸² MARGARIDA SAMEIRO, “Lei 62/2011: Algumas questões controversas na perspectiva do titular do direito” In *Revista de Direito Intelectual*, n.º 01-2015, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 309 e segs.

⁸³ LUÍS COUTO GONÇALVES, “A questão da competência do tribunal arbitral necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia meramente *inter partes*. Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Dezembro de 2016” In *Revista de Direito Intelectual*, n.º 01-2017, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 363 e segs.

⁸⁴ Perfilhamos, neste sentido, a tendência geral identificada por HANOTIAU, segundo o qual “o domínio reservado da inarbitrabilidade não cessa de se reduzir, a ponto de não mais deixar subsistir, a título de “núcleo duro” que a arbitrabilidade *erga omnes* da validade do título” (tradução nossa), “*En d’autres termes, le domaine réservé de l’inarbitrabilité ne cesse de se réduire, au point de ne plus laisser subsister, au titre de ‘noyau dur’, que l’arbitrabilité erga omnes de la validité du titre.*” *cit.*, HANOTIAU, “*L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle*”, *ASA Bulletin*, Issue 1, 2003 p. 15

⁸⁵ PEDRO SOUSA E SILVA dá nota que “leva mesmo à suspensão desses processos [de declaração de nulidade ou anulação] atenta a prejudicialidade que uma questão assume relativamente à outra”, *cit.*, *Direito Industrial...*, *op. cit.*, p. 42.

Assim, o argumento “clássico” de que os tribunais tinham competência exclusiva do art. 35.º, n.º 1 do CPI 2003 obstava ao conhecimento incidental da validade perde aqui a sua premissa: a declaração de nulidade ou anulação já não “só podem resultar de decisão judicial”, mas sim de “decisão do INPI”.

Ora, se a decisão primária do INPI sobre a validade do segundo grupo de DPI é ela própria susceptível de recurso judicial (art. 38.º, al. b) CPI) e, por essa via, arbitrável (art. 47.º, n.º 1 CPI), ainda que *institucionalmente*, afigura-se mais difícil sustentar a inadmissibilidade do conhecimento incidental da questão pelo tribunal arbitral em litígios entre privados. Seria, a nosso ver, contraditório admitir que um tribunal arbitral pode apreciar a decisão do INPI que declarou a nulidade de uma marca, mas não pode conhecer incidentalmente da validade dessa mesma marca no âmbito de um litígio de infracção.

Em sentido contrário, poder-se-á argumentar que a competência do INPI para decidir em primeira linha sobre a validade destes DPI é exclusiva, e que um tribunal arbitral – em litígios entre privados, sem intervenção do INPI como parte – não pode substituir-se àquela entidade, sequer a título incidental. Neste ponto, adquire relevância a circunstância de o 34.º, n.º 2 do CPI, *in fine*, ressaltar que a declaração de nulidade ou anulação pode também resultar “*de um pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma acção que corra termos no tribunal*” o que nos parece dar a entender que há uma maior abertura por parte do legislador para o conhecimento da validade do segundo grupo de DPI a título incidental, através de reconvenção deduzida por parte do demandado em que alega a invalidade do direito que contra si está a ser invocado, pois, como vimos, este tribunal pode ser um tribunal arbitral (e não obrigatoriamente um tribunal estadual, como no CPI 2003⁸⁶)

⁸⁶ MANUEL OEHEN MENDES, “*Breves considerações...*”, *op. cit.*, p. 936, referia que “o tema que temos vindo a abordar nada tem a ver, como é evidente, com a questão de saber se os tribunais judiciais (...) podem julgar a questão da invalidade das patentes apenas no âmbito de uma acção especialmente intentada para o efeito ou em virtude de apresentação de um pedido reconvenicional numa acção de infracção, ou se também podem apreciar esta problemática quando arguida aí como mera defesa por excepção. Na realidade, a eventual admissibilidade de todas estas vias processuais para obter a *declaração judicial de invalidade* das patentes (porque é disso que se trata), não nos permitirá concluir que, assim sendo, os tribunais arbitrais terão igualmente competência para conhecer a matéria da sua validade ou invalidade (...)” “O assunto é, obviamente outro e anterior: não o de saber se a invalidade da patente pode ser invocada como um meio de defesa, mas sim o de apurar se os tribunais arbitrais portugueses, *sic et simpliciter*, são ou não competentes, *em razão da matéria*, para apreciar esta questão”.

Concordamos com a distinção e “objecção” segundo a qual a pluralidade de vias processuais admitidas nos tribunais estaduais referidas pelo Autor nada diz sobre a competência arbitral, questão que seria “outra e anterior”; mas, com a transposição da DHM, o CPI 2018, dá uma resposta diferente sobre a questão prévia da competência, o tribunal arbitral é materialmente competente para apreciar o mérito da decisão do INPI sobre a (in)validade do registo, pelo que a premissa da exclusividade judicial que bloqueava raciocínio análogo sob o CPI 2003 deixou de estar presente. Tal depende, não obstante, da interpretação que se faça da redacção do vocábulo “tribunal” no art. 34.º, n.º 2 do CPI...

v) Notas de direito comparado

No que respeita aos DPI sujeitos a registo, DÁRIO MOURA VICENTE identifica, no direito comparado, um espectro de soluções que vão desde a: (i) não arbitrabilidade⁸⁷, (ii) arbitrabilidade com limitações⁸⁸ e (iii) arbitrabilidade total⁸⁹.

O modelo mais restritivo – hoje claramente minoritário⁹⁰ – é o da *não arbitrabilidade*. O exemplo paradigmático é a **África do Sul**, onde o art. 18(1) da *Patents Act n.º 57*, de 26 de Abril de 1978, reserva integralmente ao Comissário⁹¹ competente a jurisdição de primeira instância de qualquer questão regulada por essa lei, excluindo qualquer outro tribunal.

O modelo mais comum é o da *arbitrabilidade com limitações*. A maioria dos ordenamentos admite a arbitragem nos litígios contratuais emergentes de DPI sujeitos a registo (nomeadamente os relativos ao licenciamento e à transmissão de direitos, incluindo a apreciação de responsabilidade civil) uma vez que nestes casos não estão em causa interesses públicos⁹² que obstem a apreciação do objecto do litígio por árbitros em detrimento de um TE..

Analisando a *section 294 (a)/(c)* do *U.S. Code*, interpreta-se que a **lei norte-americana** permite que as partes convencionem uma cláusula compromissória: “*A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to the patent validity or infringement arising under the contract.*”, ou um compromisso arbitral, desde que este revista forma escrita “*In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration.*” prevendo, na mesma norma, a autonomia desta convenção de arbitragem: “*Any such provision shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract*”, a irrecorribilidade da decisão: “*An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration*”, como também a eficácia meramente *inter partes* da sentença arbitral: “*(...) but shall have no force or effect on any other persons.*” (sublinhado nosso).

⁸⁷ DÁRIO MOURA VICENTE, “*Arbitrability...*”, *op. cit.*, p.153

⁸⁸ DÁRIO MOURA VICENTE, “*Arbitrability...*”, *op. cit.*, pp. 153-157

⁸⁹ DÁRIO MOURA VICENTE, “*Arbitrability...*”, *op. cit.*, pp. 157-158

⁹⁰ “*Only very few legal systems nowadays exclude arbitration on IP disputes altogether.*”, *cit.* DÁRIO MOURA VICENTE, “*Arbitrability...*”, *op. cit.*, p. 153.

⁹¹ O art. 8.º da referida lei estabelece que o *Judge President* da Divisão Provincial de Gauteng do Supremo Tribunal da África do Sul deve designar, periodicamente, um ou mais juizes dessa divisão para servirem como *Commissioner of Patents* que presidente o *Court of the Commissioner of Patents*, que é um tribunal especializado com o mesmo estatuto de uma divisão do Supremo Tribunal. Não deve ser confundido com o *Registrar of Patents* que corresponde à entidade pública que concede através de acto administrativo o direito (subjectivo) de propriedade intelectual (cuja entidade análoga em Portugal seria o INPI).

⁹² “*Disputes regarding claims for the compensation of damage inflicted through the infringement of those rights are equally referable to arbitration in most jurisdictions, since no public interests are at stake in such cases (...)*” *cit.*, DÁRIO MOURA VICENTE, “*Arbitrability...*”, *op. cit.*, p. 153

Assim sendo, podemos concluir que no ordenamento jurídico norte-americano é permitido às partes submeter à arbitragem litígios sobre a validade ou violação de patentes, expressamente limitando os efeitos da SA às partes. A declaração de invalidade da patente, com efeitos *erga omnes*, continua, todavia, reservada à competência dos TE. Trata-se, portanto, de declarar a *inoponibilidade* do direito controvertido entre as partes do que propriamente julgar a sua validade.

No extremo oposto, situa-se o modelo de *arbitrabilidade total*, em que o TA pode pronunciar-se sobre a validade dos DPI sujeitos a registo com eficácia potencialmente *erga omnes*. Na **Suiça**, o *Institut federal de la propriété intellectuelle* reconhece às SA sobre validade de patentes e marcas desde que declaradas executória por um tribunal suíço⁹³, pelo que mesmo aquela limitação quanto aos efeitos da decisão arbitral não tem consagração.

b) Quanto à titularidade

A questão da titularidade dos direitos em causa é arbitrável, mesmo quando esses direitos estejam sujeitos a registo ou depósito. Se o ordenamento jurídico permite a transmissão desses direitos entre particulares⁹⁴ – podendo a sua titularidade ser, assim, determinada por mero negócio jurídico – não existe nenhuma consideração de interesse público que justifique a exclusão de tal matéria do âmbito da arbitragem voluntária⁹⁵.

c) Obrigações contratuais (v.g., transmissão, licenciamento)

Os litígios emergentes de contratos de licença ou de transmissão de DPI são geralmente arbitráveis. É esta a matéria em que o recurso à arbitragem se revela mais frequente no domínio em apreço⁹⁶.

d) Obrigações extracontratuais (“infracção”)

Os litígios resultantes da violação de direitos de propriedade intelectual devem ser tidos como arbitráveis uma vez que, a imposição da obrigação de reparar o dano causado a outrem, afecta fundamentalmente interesses patrimoniais privados; ela deve, pois, ser tida como pertinente ao domínio da livre disponibilidade.⁹⁷ Não podíamos deixar de dar nota que, relativamente aos *ilícitos criminais*, previstos nos arts. 318.º e segs. do CPI e 195.º e segs. do CDADC, a inarbitrabilidade é manifesta, o *ius puniendi* é prerrogativa exclusiva do Estado, indisponível pelas partes. A

⁹³ DÁRIO MOURA VICENTE, “*Arbitrability...*”, *op. cit.*, pp. 157-158. Mais desenvolvidamente, sobre o direito suíço, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...*, *op. cit.*, p. 476.

⁹⁴ Art. 30.º, n.º 1 do CPI

⁹⁵ No mesmo sentido, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...*, p. 478.

⁹⁶ No mesmo sentido, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...*, pp. 478-479.

⁹⁷ O que pode assumir relevância, conforme sublinha DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela...*, p. 479, *cit.*, “v.g., nos casos em que a uma ou ambas as partes importe preservar a confidencialidade do litígio em ordem a salvaguardar a reputação dos produtos ou serviços que coloca no mercado (...)”

arbitrabilidade do contencioso de infracção restringe-se, pois, à sua dimensão *civil*, pois é nessa que reside a *patrimonialidade* dos interesses em litígio, a que se refere o art. 1.º, n.º 1 da LAV.

4. Articulação do TA, INPI e ARBITRARE

4.1 O ARBITRARE: enquadramento institucional e evolução da arbitragem dos DPI sujeitos a registo em Portugal

A possibilidade de interposição de recurso para um tribunal arbitral foi introduzida pelo CPI 2003. O DL n.º 143/2008, de 25 de Julho⁹⁸, procurou aperfeiçoar o regime do recurso arbitral previsto no CPI 2003, preparando também a entrada em funcionamento de um centro de arbitragem com competência para dirimir litígios em matéria de propriedade industrial, nomes de domínio, firmas e denominações, que, por lei especial, não sejam submetidos exclusivamente a tribunal judicial ou arbitragem necessária⁹⁹. O ARBITRARE, constituído como uma pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos é o centro de arbitragem referido, criado em 2008, através do Despacho n.º 28519/2008, de 22 de Outubro. Em 2011, foi instituída a disciplina da arbitragem relativa aos litígios envolvendo patentes de medicamentos de referência e medicamentos genéricos, com carácter *necessário*, que, com a aprovação do CPI 2018, passou a revestir natureza *voluntária*, conforme desenvolvemos *supra*¹⁰⁰.

4.2 Notas sobre a vinculação genérica do INPI à jurisdição do ARBITRARE

A vinculação genérica do INPI ao ARBITRARE resulta da Portaria n.º 1049/2009, conforme previsto no art. 48.º, n.º 4 do CPI¹⁰¹. Nos termos desta Portaria, o INPI vinculou-se à jurisdição do ARBITRARE¹⁰² para a composição de litígios de valor igual ou inferior a um milhão de euros que tenham por objecto matérias relativas a propriedade industrial¹⁰³. Com a criação da DED em 2019 e a consequente atribuição da competência decisória, extraindo-a da reserva judicial, sobre os pedidos de declaração de nulidade ou anulação do segundo grupo de DPI sujeitos a registo para o INPI, o “perímetro” do ARBITRARE foi, na prática, alargado: as decisões da DED

⁹⁸ Mediante o programa SIMPLEX, este Decreto-lei aprovou medidas de simplificação e acesso à propriedade industrial, alterando o CPI, nomeadamente introduzindo a *possibilidade* de vinculação genérica do INPI a centros de arbitragem institucionalizada.

⁹⁹ Tal como resulta do art. 3.º, n.º 2 dos Estatutos do ARBITRARE.

¹⁰⁰ “Na sequência da crise financeira de 2011, o “Memorando de Entendimento” celebrado entre o governo português e os membros da “troika” determinava que fossem removidas *todas as barreiras à entrada de genéricos, especialmente através da redução de barreiras administrativas/legais, com vista a acelerar a comparticipação de genéricos*. Com esse objetivo, foi decidido criar um mecanismo rápido e eficiente para julgar os litígios opondo titulares de patentes de medicamentos de referência e empresas de medicamentos genéricos que tenham pedido autorizações de introdução no mercado (“AIM”); *cit.*, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, *op. cit.*, p. 655

¹⁰¹ À data, art. 49.º, n.º 4 do CPI 2003.

¹⁰² Art. 1.º, n.º 1 da Portaria n.º 1049/2009

¹⁰³ Nos termos do art. 1.º, n.º 1 e n.º 2 da Portaria n.º 1049/2009

relativas a estes registos são agora susceptíveis de recurso judicial (art. 38.º, al. b) do CPI) e, por isso, arbitráveis (art. 47.º, n.º 1 do CPI), podendo o ARBITRARE, com fundamento na vinculação genérica *ex vi* art. 48.º, n.º 4 do CPI, ser competente para apreciar o correspondente contencioso arbitral. Importa referir, ainda que sucintamente, que, ao contrário do que ocorre em sede de recurso judicial, em que o INPI não é considerado “*em caso algum*” parte contrária (art. 43.º, n.º 5 CPI), em sede arbitral, o INPI é parte litigante, nos termos do 48.º, n.º 3 do CPI. Sendo o INPI um instituto público, logo, uma pessoa colectiva pública, para efeitos de arbitrabilidade subjectiva, o INPI pode ser parte de um processo arbitral uma vez que o art. 1.º, n.º 5 da LAV estabelece que “*O Estado e outras pessoas colectivas de direito público podem celebrar convenções de arbitram, na medida que estejam autorizadas por lei (...)*” – não se aplicando a segunda parte do art. 1.º, n.º 5 da LAV, uma vez que o INPI não se encontra numa posição de horizontalidade face à contraparte.

5. Conclusão

Quanto às especificidades da arbitragem voluntária neste domínio, o regime do CPI consagra dois desvios ao regime-regra da LAV: (i) a recorribilidade da SA, que de excepção convencional (art. 39.º, n.º 4 LAV) se torna regra geral sempre que o INPI esteja vinculado à convenção de arbitragem (art. 48.º, n.º 5 CPI); e (ii) a publicidade da decisão, que pode ser determinada pelo próprio TA ao abrigo do art. 47.º, n.º 3 do CPI, derogando, assim, o princípio geral da confidencialidade do PA. Estas opções legislativas radicam, em última análise, na *natureza* dos direitos em causa: porque os DPI sujeitos a registo produzem efeitos *erga omnes*, e resultam de um acto administrativo de concessão do título, justifica-se uma maior abertura ao controlo jurisdicional, consequentemente, uma compressão do sigilo que é apanágio da AV.

Quanto às vantagens e limitações, a celeridade e a especialização técnica dos árbitros conferem à arbitragem uma “atração” particular para os litígios neste domínio, em que o *thema decidendum* cruza conhecimentos jurídicos e conhecimentos técnicos. A confidencialidade, em contrapartida, merece ser tida com cautela: consoante o DPI em causa, ela pode ser erodida pela própria publicidade do registo (que permite identificar as partes mesmo quando a SA é “(...) *expurgada de elementos de identificação das partes*” cfr. art. 30.º, n.º 6 LAV) e esta confidencialidade pode mesmo ser derogada, nos termos já indicados. Subsiste, em todo o caso, uma confidencialidade *relativa*, sobretudo quanto aos articulados, à prova produzida, etc.

Quanto à arbitrabilidade, que é o núcleo central do presente trabalho, o regime português é hoje um regime dual quanto à validade dos DPI sujeitos a registo. Nos DPI relacionados com a tutela da inovação técnica, mantém-se a tradição (“núcleo duro”) da inarbitrabilidade da

apreciação principal e com efeitos *erga omnes* (art. 34.º, n.º 1 do CPI). Quanto aos demais (segundo grupo, DPI relacionados a tutela da inovação estética e outros sinais distintivos, art. 34.º, n.º 2 do CPI), o contencioso das decisões (administrativas) da DED/INPI é arbitrável *institucionalmente*, arts. 47.º, n.º 1 *ex vi* art. 38.º, al. b) CPI. A propósito da apreciação incidental da invalidade, defendemos que ela deve ser admitida em ambos os grupos, com eficácia meramente *inter partes*: no primeiro grupo, porque a pronúncia que se limite à *inoponibilidade* do direito entre as partes do PA não colide com a competência exclusiva dos tribunais estaduais para “a declaração de nulidade ou anulação (...)” com efeitos *erga omnes* (art. 34.º, n.º 1 CPI); no segundo grupo, dada a transposição da DHM, o tribunal arbitral é materialmente competente para apreciar o mérito da decisão do DED/INPI sobre a (in)validade do registo; dada a referência expressa do art. 34.º, n.º 2 CPI *in fine* ao pedido reconvenicional, parece-nos que há uma maior abertura do legislador ao conhecimento da invalidade neste contexto; mais pertinentemente, a nosso ver, a solução contrária obrigaria à suspensão da instância arbitral por prejudicialidade, esvaziando, em larga medida, as próprias vantagens da arbitragem e oferecendo ao demandado um expediente fácil para bloquear, de má-fé, o processo. Já no plano dos DPI não sujeitos a registo, sublinhamos a inarbitrabilidade dos direitos morais de autor, a arbitrabilidade dos direitos patrimoniais (com a excepção do *droit de suite*) e a existência de arbitragem necessária relativamente a alguns, já com duas décadas de história, por opção do legislador, aquando da transposição de Diretivas ainda “comunitárias”.

Quanto à articulação entre o TA e as entidades administrativas, o ARBITRARE constitui hoje a “peça central” no contencioso arbitral em matéria de propriedade industrial, dada a vinculação genérica do INPI à jurisdição daquele. A criação da DED em 2019 alargou, na prática, o perímetro de actuação do ARBITRARE, ao deslocar para o INPI a competência para a declaração de nulidade ou anulação do segundo grupo de DPI sujeitos a registo.

Em suma, o regime português configura um modelo de arbitrabilidade com limitações, em que o legislador procura conciliar a abertura à arbitragem dos litígios entre privados com a salvaguarda da função pública do registo. As tensões que dele resultam não estão integralmente resolvidas pela letra da lei. Entendemos que o sentido evolutivo do sistema, todavia, é claramente expansivo, exigindo da doutrina e da jurisprudência uma compreensão cada vez mais fina das condições em que o tribunal arbitral pode legitimamente pronunciar-se sobre a validade, sem invadir a reserva de jurisdição judicial/administrativa.

Lista de bibliografia consultada

ALBERTO SÁ E MELLO, Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos, 6.º edição, Almedina, Coimbra, 2025

ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, “*Arbitragem e propriedade industrial: medicamentos de referência e medicamentos genéricos*”, In Revista de Legislação e Jurisprudência, 144.º ano, Julho-Agosto de 2015, n.º 3993

ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem de Litígios com Entes Públicos, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2015,

ANTÓNIO CAMPINOS, LUÍS COUTO GONÇALVES, et al. (coordenadores), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2015

ARMINDO RIBEIRO MENDES... [et al.], Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, Almedina, Coimbra, 2012

CÉSAR BESSA MONTEIRO “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, In Jornal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Anos XIII, n.º 4, Dezembro 1998

DÁRIO MOURA VICENTE,

“*Arbitrability of intellectual property disputes: a comparative survey*”, In *Arbitration International*, vol. 31, Oxford University Press, 2015

A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2019

ELSA DIAS OLIVEIRA, Arbitragem Voluntária – Uma Introdução, Almedina, Coimbra, 2020, reimpressão, 2021

EVARISTO MENDES, “*Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efetiva e Questões Conexas*”, In Propriedades Intelectuais, 2015, n.º 3

HANOTIAU, “*L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle*”, ASA Bulletin, Issue 1, 2003

JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES,

“*A arbitrabilidade da exceção de invalidade de patente no quadro da Lei n.º 62/2011. Anotação ao Acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de fevereiro de 2014 (proc. n.º 1053/13.7YRLSB-2)*” In Revista de Direito Intelectual, n.º 02-2014, Almedina, Coimbra, 2014

“*A arbitrabilidade dos litígios e a dedução de providências cautelares por empresas de medicamentos de referência, na sequência da aprovação de medicamentos genéricos*”, In Revista de Direito Intelectual, n.º 01-2014, Almedina, Coimbra, 2014

“*Bis in idem: em torno da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a questão da invalidade da patente com efeitos inter partes - anotação ao acórdão do STJ de 14 de Dezembro de 2016 (proc. n.º 1248/14.6YRLSB.S1)*”, In Revista de Direito Intelectual, n.º 01-2017, Almedina, Coimbra, 2017

JOSÉ ALBERTO VIEIRA, “*A competência de tribunal arbitral necessário para apreciar a exceção de invalidade de patente registada. Anotação ao Acórdão da Relação de Lisboa de 13 de Janeiro de 2015*” In Revista de Direito Intelectual, n.º 02-2015, Almedina, Coimbra, 2015

JOSÉ MIGUEL JÚDICE, “*A constituição do tribunal arbitral: características, perfis e poderes dos árbitros*” In 2.º Congresso de Arbitragem da ACL, 2008.

LUÍS COUTO GONÇALVES, “*A questão da competência do tribunal arbitral necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia meramente inter partes. Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Dezembro de 2016*” In Revista de Direito Intelectual, n. º01-2017, Almedina, Coimbra, 2017

MANUEL OEHEN MENDES “*Breves considerações sobre a incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes e dos Certificados Complementares de Proteção para Medicamentos*”, In DÁRIO MOURA VICENTE et al. (coordenadores), *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, 2015

MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, Almedina, Coimbra 2010

MARGARIDA SAMEIRO, “*Lei 62/2011: Algumas questões controversas na perspetiva do titular do direito*” In Revista de Direito Intelectual, n. º01-2015, Almedina, Coimbra, 2015

NUNO SOUSA E SILVA, *Lições de Direito Digital*, Almedina, Coimbra, 2026

OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos conexos: Direito Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 1992, reimpressão, 2008

PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2025

VÍTOR PALMELA FIDALGO, “*Proposta para a implementação de legislação sobre resolução alternativa de litígios em matéria de direito de autor e direitos conexos (Parecer)*” In *Propriedades Intelectuais*, jun/nov 2023, n.ºs 19 e 20

Lista de jurisprudência e sentenças arbitrais

[Tribunal Constitucional, Acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, Relatora: Conselheira MARIA DE FÁTIMA MATA-MOUROS](#)

[Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão de 14 de Dezembro de 2016, N.º de Processo: 1248/14.6YRLSB.S1, Relator: LOPES DO REGO](#)

[ARBITRARE, Processo n.º 91/2025, “vinhosverdes.pt”](#)

[ARBITRARE, Processo n.º 17/2024 “registo da marca nacional n.º 707581 “SOLAR DOS PRESUNTOS”](#)